

1500819-11.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela da Conceição Rodrigues

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... de suspeição" (RT614/275).

Prova. Tráfico de entorpecentes. Depoimento de policiais Valor no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a palavra de policiais, quando esclarecedora e detalhada, além de respalda danos elementos indiciários colhidos, constitui prova hábil para a condenação, ainda mais se as testemunhas da defesa não puderam desfazer a versão por eles relatada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n º01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500819-11.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500819-11.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2078072/2022 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 23760040 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 725/22/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2078072

- DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE PAZ MARCELINO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

Caio Emanuel Gonçalves Nunes (nascido em 11/08/1999) e André Paz Marcelino (nascido em 20/07/1988) foram denunciados como incursos nos termos do art. 33, caput, c.c. o art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois, segundo consta da denúncia (fls. 264/265), no dia 21/03/2022, por volta das 15h30min, nas dependências da Penitenciária Nilton Silva, localizada na Rodovia Edgar Máximo Zambotto, Km 44, Vila Machado, nesta cidade e comarca de Franco da Rocha, André trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, 75,8g de tetrahydrocannabinol, conforme auto de exibição e apreensão (fl. 05), laudo de constatação preliminar (fls. 07/09) e laudo definitivo (fls. 326/328), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Igualmente consta que, nas mesmas condições de tempo e local descritas no parágrafo anterior, Caio trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, 10,96g de

tetrahidrocannabinol, conforme auto de exibição e apreensão (fl. 05), laudo de constatação preliminar (fls. 07/09) e laudo definitivo (fls. 326/328), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Recebida a denúncia em 28/03/2022 (fl. 269), os réus foram citados (fls. 304 e 306) e apresentaram resposta à acusação (fls. 309/310).

Não constatada hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), designou-se audiência de instrução e julgamento na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório.

Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus. As defesas requerem absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a aplicação de pena mínima.

É o relatório

Passo a decidir.

No mérito, o pedido condenatório é parcialmente procedente.

A materialidade do crime vem demonstrada por meio do: auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição de apreensão (fl. 05), laudo pericial definitivo (fls. 326/328), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

Ouvidos perante a autoridade policial, o réu Caio Emanuel Gonçalves Nunes manteve-se em silêncio (fl. 13).

Em juízo, Caio disse que os fatos são parcialmente verdadeiros. Disse que estava voltando da saída temporária e encontrou com outros presos que lhe ofereceram duas porções de maconha. Colocou as duas porções na cueca. Eles iriam jogar fora o entorpecente por não conseguirem mais engolir. Esse entorpecente era para seu uso. Não conhecia esses indivíduos que lhe entregaram os entorpecentes. Não conhecia André ele estava em raio diferente do depoente.

O réu André Paz Marcelino, perante a autoridade policial, também exerceu o direito constitucional ao silêncio (fl. 17).

Em juízo, André negou a prática do delito de tráfico. Disse que na volta da saída foi surpreendido com os entorpecentes. Levou os entorpecentes para seu uso pessoal. Comprou as drogas na Zona norte e as colocou na cueca. Faz uso de maconha, crack e cocaína. Na cadeia tem detentos que vendem drogas e é mais cara que na rua.

A versão apresentada pelos acusados se encontra em consonância parcial com o cenário probatório obtido.

Eduardo Pinheiro Gonzales, agente penitenciário, na Delegacia de Polícia, disse que na data dos fatos a foi destacado para operar o aparelho de scanner corporal, utilizado para revista de presos que retornam das saídas temporárias. Os internos retornaram da saída temporária do mês de março, sendo que o depoente, ao visualizar a imagem dos detentos André Paz Marcelino e Caio Emanuel Gonçalves Nunes, quando submetidos ao aparelho scanner, notou que havia diversos objetos estranhos na altura da cintura de ambos os detentos. Considerando que é extremamente comum que os detentos retornem trazendo consigo drogas, o depoente logo imaginou que ambos estivessem trazendo drogas escondidas nas vestes, razão pela qual deles indagou se estavam em poder de algo ilícito, ao que ambos admitiram de pronto que traziam consigo porções individuais de drogas. André trazia cerca de 28 trouxinhas de maconha, pesando aproximadamente 83g, as quais estavam escondidas no elástico de sua cueca. Caio trazia consigo cerca de 4 trouxinhas de maconha – e mais uma porção solta –, pesando aproximadamente 13g, as quais estavam escondidas em sua cueca. Os detentos nada declararam quanto à origem e ao destino das drogas. O diretor do presídio tomou conhecimento dos fatos, determinou a elaboração dos comunicados de Evento 63/2022 e 65/2022, bem como que os detentos fossem conduzidos ao distrito policial. O depoente não sabe precisar qual o valor da porção de maconha no interior do sistema penitenciário (fl. 10).

Em juízo, a testemunha disse que trabalhava no setor de revistas da PII na época dos fatos. Ambos, ao passaram pelo aparelho de scanner corporal, que era operado pelo depoente. Os réus estavam portando objetos na região da cintura, na cueca. Feita a revista, localizaram os entorpecentes e os réus admitiram estar trazendo

entorpecentes.

Fagner Diego Almeida Gonzaga, agente penitenciário, na Delegacia de Polícia, confirmou o que sua colega de trabalho disse (fl. 12).

Em juízo, a testemunha disse que estava organizando a fila do retorno dos presos. Eduardo, seu colega, estava operando a máquina. Viram uma imagem alterada na região da cintura dos acusados. Questionados eles admitiram estar trazendo entorpecentes. Os dois estavam com a droga na cueca. Primeiro foi passado o réu André no scanner. Posteriormente foi passado Caio que também admitiu portar drogas. A droga de Caio estava no fundo da cueca, em um forro, e a de André estava no elástico da cueca. Foram tiradas fotos da droga localizada.

Quanto aos agentes de segurança ouvidos, não há indícios de que tinham motivos para acusar os réus de forma leviana e gratuitamente, até porque sequer os conheciam.

Neste diapasão:

"Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido." (JTJ 208/273). "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT614/275).

Prova. Tráfico de entorpecentes. Depoimento de policiais Valor no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a palavra de policiais, quando esclarecedora e detalhada, além de respalda danos elementos indiciários colhidos, constitui prova hábil para a condenação, ainda mais se as testemunhas da defesa não puderam desfazer a versão por eles relatada em juízo." (TACrim, 12ª Câmara, rel. Desembargador João Morenghi, Apelação 1473255/5).

Assim, não procede a afirmação de inexistência de provas suficientes para a condenação do acusado André pelo delito de tráfico de drogas. Observo, ainda, que os depoimentos foram coerentes e harmônicos, de modo que eventual discrepância, se houve, não foi suficiente para retirar o valor probante que deles emana. A quantidade de droga apreendida, e os depoimentos prestados pelas agentes penitenciárias ouvidas, levam à certeza de que o acusado guardava e transportava drogas na ocasião, impondo-se, pois, a sua condenação.

Cabe assinalar que a denúncia imputa ao réu a conduta de "ter em depósito, guardar, e transportar, para entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente", e não de vender drogas, razão pela qual os fatos descritos na denúncia encontram-se perfeitamente provados em instrução.

Não há que se falar em atipicidade da conduta por crime impossível ou tentativa, em razão de o tráfico de drogas ter se consumado no instante em que os réus traziam consigo os entorpecentes para o consumo alheio (crime de ação múltipla e formal), além de o meio utilizado, levar drogas escondidas sob as suas vestes para o presídio, ser absolutamente eficaz e conhecido para a prática do delito. Do contrário, não haveria a entrada de entorpecentes em estabelecimento prisionais, fato conhecido por todos.

Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJSP: RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DELITO UNISSUBSISTENTE. REVISTA ÍNTIMA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento de violação do art. 619 do Código de Processo Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte em relação à conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento. 2. Não houve nenhuma contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade no julgado proferido pela Corte de origem, de modo a gerar o pretendido reconhecimento de violação do art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto o Tribunal a quo efetivamente externou as razões pelas quais entendeu configurada a apontada nulidade arguida pela defesa

(relativa à ordem do interrogatório) e considerou devida a absolvição da acusada. 3. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível, por isso mesmo, a sua ocorrência na modalidade tentada. 4. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Precedentes. 5. Em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), inequívoca a conclusão de que o delito ocorreu em sua forma consumada, na modalidade "trazer consigo" ou "transportar". Vale dizer, antes mesmo da abordagem da acusada pelos agentes penitenciários, o delito já havia se consumado com o "trazer consigo" ou "transportar" drogas (no caso, 143,7 g de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Inviável, por conseguinte, a aplicação do instituto do crime impossível. 6. Conquanto seja possível inferir que a revista pessoal tenha por objetivo evitar a entrada de armas, explosivos, drogas, aparelhos celulares e outros similares em estabelecimentos prisionais, sua existência apenas minimiza o ingresso de tais objetos no presídio. 7. Não obstante a acusada tivesse o direito de se recusar ser revistada intimamente, submeteu-se, de maneira voluntária, ao procedimento adotado no estabelecimento prisional, que resultou na localização, no interior de sua vagina, de 143,7 g de maconha, acondicionados dentro de um preservativo, os quais seriam entregues a seu companheiro, que estava preso no local. Assim, não houve ato ofensivo à honra da acusada, tampouco dano à sua integridade física ou moral. 8. As pessoas que se dirigem ao presídio sabem, previamente, que podem ser submetidas à revista pessoal e minuciosa. Trata-se, tal procedimento (quando realizado com estrita observância a procedimento legal e com respeito aos princípios e às garantias constitucionais), de legítimo exercício do poder de polícia do Estado, de cunho preventivo, o qual objetiva garantir a segurança social e os interesses públicos. 9. Caso haja fundadas suspeitas de que o visitante do presídio esteja portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, com fins de segurança, a qual, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente quando realizada dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem nenhum procedimento invasivo, tal como ocorreu na espécie dos autos. Precedentes. 10. Por ocasião do julgamento do HC n. 127.900/AM, ocorrido em 3/3/2016 (DJe 3/8/2016), o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais. Isso porque a Lei n. 11.719/2008 (que deu nova redação ao referido art. 400) prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em legislação especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado (lex mitior), já que assegura maior efetividade a princípios constitucionais, notadamente aos do contraditório e da ampla defesa. 11. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica dos feitos já sentenciados (CF, art. 5º, XXXVI), houve modulação dos efeitos da decisão: estabeleceu que essa orientação somente deve ser aplicada aos processos cuja instrução ainda não se haja encerrada. 12. Recurso especial provido, nos termos do voto do relator. REsp 1523735/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES RECURSO DA ACUSAÇÃO PRETENDIDA A REDUÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA DOS RÉUS LEANDRO E DOUGLAS PELA APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS NÃO ACOLHIMENTO QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA NÃO SE MOSTRA EXACERBADA A PONTO DE IMPEDIR O REDUTOR MÁXIMO A TENTATIVA DE LEVAR DROGAS PARA DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL JÁ FOI CONSIDERADA NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. III, DA LEI DE DROGAS INVIÁVEL SUA UTILIZAÇÃO PARA MODULAR O REDUTOR, SOB PENA DE BIS IN IDEM - RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DAS DEFESAS DOS RÉUS ADILSON E DIEGO PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS PENAS E REGIME INICIAL FECHADO MANTIDOS RECURSOS NÃO PROVIDOS. RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS LEANDRO E DOUGLAS PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA ALEGAÇÃO DE CRIME

IMPOSSÍVEL NÃO ACOLHIMENTO CRIME FORMAL - NÃO DEMONSTRADA, ADEMAIS, A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO UTILIZADO PARA EFETIVAR A INTRODUÇÃO DOS ENTORPECENTES NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL CRIME, ADEMAIS, CONSUMADO ANTES MESMO DE TENTAR INTRODUIR A DROGA NO PRESÍDIO PENAS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS CONFISSÃO NÃO POSSIBILITA REDUÇÃO DA PENA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO COL. STJ INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INC. V, DA LEI DE DROGAS, QUANTO AO RÉU DOUGLAS, QUE ADQUIRIU O ENTORPECENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO REGIME INICIAL MITIGADO PARA O ABERTO CONCEDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJSP; Apelação Criminal 0002143-95.2017.8.26.0638; Rel. Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 13/09/2021; Data de Registro: 20/09/2021).

Por fim, o crime praticado por André se deu no interior de um presídio, conforme relato unânime da prova oral e demais documentos que instruem o feito, devendo incidir a causa de aumento prevista no inc. III, do art. 40, da Lei de Drogas. A quantidade de entorpecentes trazida por André na ocasião não é compatível com a de simples usuário. Estava de posse de 75,8g de maconha, em 28 invólucros em clara indicação de que este entorpecente destinava-se a terceiros. Não se mostra crível que corresse tamanho risco com elevada quantidade de drogas apenas para seu uso. A condenação pelo crime de tráfico por André, portanto, é medida que se impõe. Em relação a Caio, não há elementos seguros nos autos que indiquem que os entorpecentes com ele apreendidos sejam destinados a terceiros. A quantidade de maconha de posse de Caio é compatível com a posse para uso pessoal. Assim, deve a conduta ser declassificada para aquela prevista no art. 28 da lei 11.343/06. Para fins de efetividade do processo, entendo possível a aplicação imediata da pena sendo desnecessária a remessa ao Juizado Especial Criminal.

Passo a dosar as penas.

Quanto ao réu André Paz Marcelino:

Sopesados os elementos norteadores do art. 59 do Código de Penal, verifico que o réu André apresenta maus antecedentes (0003313-14.2017.8.26.0635/0009965-83.2017.8.26.0041 - fl. 277). As demais circunstâncias judiciais foram as típicas à espécie. Assim, elevo a pena base em 1/8, perfazendo a pena base de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias multa.

Na segunda fase, ausente qualquer atenuante eis que negou que a droga destinasse a terceiros. O réu é multirreincidente específico (0048020-13.2016.8.26.0050/0007210-04.2017.8.26.0521 - fls. 277/278 e 1505195-23.2019.8.26.0228/0011818-59.2019.8.26.0041 - fl. 278), razão pela qual, deve prevalecer a agravante. Assim, elevo a pena 1/5, perfazendo a pena intermediária de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 674 (seiscentos e setenta e quatro) dias-multa. Na terceira fase, reputo presente a causa de aumento prevista no inc. III do art. 40 da Lei Antidrogas, na medida em que, pelos relatos dos agentes penitenciários, ficou evidente que o delito foi praticado no interior de estabelecimento prisional e, por isso, tendo este tráfico a especial finalidade de introduzir a droga naquele local, mas por não ter provas de que o entorpecente tenha chegado às mãos de outros presidiários, a pena será aumentada de 1/6, passando para 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 786 (setecentos e oitenta e seis) dias-multa.

Entendo ser inaplicável a redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 ao caso, uma vez que o réu é multirreincidente específico (0048020-13.2016.8.26.0050/0007210-04.2017.8.26.0521 - fls. 277/278, 1505195-23.2019.8.26.0228/0011818-59.2019.8.26.0041 - fl. 278 e 0003313-14.2017.8.26.0635/0009965-83.2017.8.26.0041 - fl. 277), o que demonstra que faz da prática delituosa o seu meio de vida.

Nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do Código Penal, considerando a condição econômica do réu, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

A pena será cumprida em regime inicial fechado, nos termos do que determina o art. 33 do CP.

Ante o quantum da pena aplicada, inviável a aplica dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Quanto ao réu Caio Emanuel Gonçalves Nunes:

Considerando seus antecedentes criminais assim como o fato de estar ingressando com entorpecentes em unidade prisional, aplico ao réu a pena de prestação de serviços à comunidade por 05 meses.

Ante o exposto e o mais do que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e condeno o réu André Paz Marcelino como incursos nas sanções do art. 33, caput, c.c. o art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 786 (setecentos e oitenta e seis) dias-multa.

Desclassifico a imputação inicial e condeno o réu Caio Emanuel Gonçalves Nunes como incurso nas sanções do art. 28 da lei 11.343/06 às penas de 05 meses de prestação de serviços à comunidade.

Tendo respondido ao processo preso, o réu André não poderão recorrer em liberdade, eis que subsistem os motivos que ensejaram sua prisão, em especial após a prolação de sentença condenatória a pena de mais de sete anos de reclusão.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado Caio face à pena imposta.

Com o trânsito em julgado, anote-se o resultado definitivo no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, TRE e Guia à VEC nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

Custas na forma da lei. Tendo sido assessorados pela defensoria pública, defiro aos réus a gratuidade de justiça.

P.I.C.

Franco da Rocha, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA